

FORMATION EN PASSATION DE MARCHÉS**Atelier Travaux**

Evaluation d'une offre

**« Conforme ou non conforme ? »,
telle est la question.**

CORRECTION

1. Évaluation de la conformité technique de l'offre de GOBI :

Pour de gros marchés de travaux, il est presque inévitable que les offres techniques remises ne puissent être conformes en tout point aux spécifications du dossier d'appel d'offres. Dans l'évaluation des offres, la difficulté réside dans la détermination du caractère acceptable ou non (majeur ou mineur) des déviations constatées.

Dans le dossier d'appel d'offres, la liste des informations à fournir par les soumissionnaires au stade de l'offre est longue : formulaires, description de l'équipe de conception (incluant CV), liste des documents de la conception détaillée, rapport de conception préliminaire, et description de points spécifiques et pointus listés en fin de section 1 de l'annexe 1. Ces informations sont disséminées à plusieurs endroits du dossier d'appel d'offres, ce qui complique à la fois la tâche des soumissionnaires dans la préparation de leur offre et l'évaluation technique des offres.

Il est mentionné dans le rapport d'évaluation des offres qu'un certain nombre d'informations demandées manque dans l'offre de GOBI : principalement, on peut citer (1) les documents et rapport de conception préliminaire, (2) les CV de l'équipe de design et (3) la description du traitement des points spécifiques. Par ailleurs, l'offre contient tous les formulaires et de nombreuses informations autres.

- (1) Concernant la conception de l'ouvrage, il apparaît dans l'énoncé du périmètre des travaux qu'une conception assez avancée de l'ouvrage a déjà été réalisée et qu'elle est même incluse dans le dossier d'appel d'offres (volume D avec schémas, plans et rapport de conception pour un total de plus de 200 pages !). Même si une certaine liberté est donnée aux soumissionnaires pour proposer leur solution, il est indiqué que la solution de référence doit se conformer à celle incluse dans le dossier d'appel d'offres. C'est l'illustration d'un cas rencontré assez fréquemment dans les marchés publics où la maîtrise d'ouvrage souhaite lancer un appel d'offres en conception-réalisation alors que la conception est déjà plus ou moins définie et qu'elle souhaite l'imposer (sans exactement le dire). Il s'agirait davantage ici d'un marché de travaux classique où les soumissionnaires sont encouragés à proposer des variantes plutôt que d'un réel marché en conception-réalisation.

Dans ces conditions, le soumissionnaire GOBI a indiqué qu'il respectera en tout point la conception spécifiée dans le dossier d'appel d'offres et n'a par conséquent pas remis les documents et rapports de conception demandés au stade de l'offre puisqu'il estime que ceux fournis par la maîtrise d'ouvrage sont suffisamment détaillés.

Il paraît difficile de disqualifier cette offre qui propose de respecter le projet d'avant-projet sommaire fourni.

- (2) L'absence des CV de l'équipe de Design pose un réel problème d'évaluation de la conformité de la qualité de l'équipe en charge de la conception. A ce titre, cette absence aurait pu justifier un rejet de l'offre pour non-conformité substantielle (déviation majeure). Cependant, il apparaît dans le rapport d'évaluation que la maîtrise d'ouvrage a pris l'initiative, dans le cadre d'une demande de clarifications, de donner la possibilité au groupement GOBI de fournir les CV manquants. Les CV ont été communiqués et ont été évalués. Le résultat de cette évaluation est satisfaisant. Dans ces conditions, il n'est plus possible de rejeter l'offre sur la base de l'absence de ces CV. La maîtrise d'ouvrage aurait dû consulter l'AFD avant de donner cette chance au soumissionnaire GOBI de compléter son offre.
- (3) Concernant l'absence de description du traitement des points spécifiques, avant de procéder à un rejet de l'offre, il convient d'une part de vérifier si des éléments de réponse ne sont pas inclus dans le reste de l'offre technique (sur certains points comme les phases de construction, la planification globale, les quelques « questions cruciales spécifiques à la conception/construction », les emplacements de carrière, il est probable que l'offre technique décrive au moins partiellement ces aspects), et d'autre part d'évaluer le caractère majeur ou mineur de l'absence de ces informations au stade de l'offre : par exemple, le programme d'expertise topographique globale, la gestion des interfaces avec les autres entrepreneurs, la

construction des routes d'accès, l'actualisation de la cartographie, paraissent pouvoir être spécifiés plus tard dans le cadre de la conception détaillée, sans constituer des informations cruciales au stade de l'offre pour juger de la capacité du soumissionnaire à réaliser les travaux.

En conclusion, sous réserve d'investigations complémentaires qui détermineraient le caractère inacceptable d'une information manquante au stade de l'offre (dans le contenu des formulaires remis par exemple), le rejet de l'offre technique de GOBI comme substantiellement non conforme paraît fragile à défendre sur la base des informations communiquées dans l'exercice.

2. Évaluation de la conformité de la proposition ESSS de l'offre de GOBI :

Le DAO utilisé reprend le renforcement des exigences ESSS du DAO type AFD : identification des sujets ESSS du chantier présentant un fort risque d'impacts et exigence de la part des soumissionnaires d'une méthodologie détaillée sur leur manière concrète de conduire le chantier pour traiter l'ensemble de ces enjeux. Cette méthodologie ESSS sera comparée aux spécifications ESSS du DAO pour déterminer si elle est conforme pour l'essentiel. La première page des spécifications ESSS à remplir par la maîtrise d'ouvrage fait état de trois sujets ESSS identifiés comme sensibles : l'organisation ESSS du chantier, la sécurité sur le chantier, et la prévention des pollutions (gestion des effluents). Sur ces points, il est exigé une méthodologie détaillée et spécifique au chantier sous peine de rejet de l'offre. Par ailleurs, la maîtrise d'ouvrage a souhaité ajouter une exigence de lister la réglementation locale environnementale applicable dans son offre.

L'offre de GOBI sur les aspects ESSS n'est pas succincte : le document inclus dans l'exercice contient 20 pages qui couvrent les aspects organisationnels (plans à établir, ressources mobilisées, suivi des impacts ESSS, formation et inspections, communication), les enjeux environnementaux, les enjeux de sécurité et de santé. Une liste des lois ESSS du pays est également fournie en fin de section. Même si beaucoup d'informations fournies restent d'ordre général, il est difficilement envisageable de déclarer l'offre ESSS substantiellement non conforme au motif qu'elle serait trop succincte (bâclée).

La gestion des effluents est détaillée à l'article b. du chapitre 8 et plus de deux pages de texte lui sont consacrées. Des détails techniques sur les installations qui seront mises en place pour la prévention des pollutions sont fournis. Ce sujet délicat a d'ailleurs été identifié dès le début de l'offre ESSS à deux reprises dans le chapitre des obligations environnementales requises (il figure dans le contenu du PGES-Chantier proposé et est repris comme premier point d'attention dans le dernier paragraphe). Sans préjuger de la pertinence des mesures proposées pour empêcher la pollution des eaux et sols, l'offre ESSS du groupement GOBI répond à l'exigence.

Comme indiqué précédemment, l'offre ESSS du groupement GOBI couvre donc l'ensemble des sujets ESSS, y compris les références à la réglementation locale. En conclusion, sur la base des informations fournies dans l'énoncé, il ne semble pas justifié de déclarer l'offre ESSS du groupement GOBI comme substantiellement non conforme.

3. Examen du prix de l'offre de GOBI

Le traitement des offres anormalement basses se fait au travers de la clause 36 des instructions aux soumissionnaires (IS) du dossier d'appel d'offres (extrait fourni dans l'énoncé). La clause fait référence à des offres inférieures de 20% à l'estimation faite par le Maître de l'Ouvrage ». La question préliminaire qui se pose est de savoir si l'offre de GOBI est inférieure de plus de 20% à l'estimation ou pas. L'offre de GOBI à 37M€ est inférieure de 22% à l'estimation de 47.45M€ faite par la maîtrise d'ouvrage. Par conséquent les dispositions de la clause 36 des IS s'appliquent.

En application de cette clause, la maîtrise d'ouvrage a sollicité le groupement GOBI pour qu'il fournisse les décompositions et détails de ses prix. Le détail du poste « matériaux » est fourni dans l'énoncé.

Selon la clause 36 des IS, l'évaluation doit rechercher, à la lecture de ces détails de prix, si des incohérences entre l'offre technique et l'offre financière ou des non-conformités de l'offre avec les spécifications techniques du dossier d'appel d'offres peuvent être mises en évidence. Dans de tels cas, l'offre sera rejetée.

A la lecture du tableau de décomposition du prix global, certains prix de l'offre de GOBI apparaissent très inférieurs aux prix de l'offre de Eiffel et/ou à l'estimation de la maîtrise d'ouvrage. On peut citer (1) le prix de mobilisation de l'entreprise, (2) le prix du laboratoire, (3) le prix des investigations géotechniques, (4) le prix des matériaux, et (5) le prix des équipements hydromécaniques.

Concernant les matériaux et les équipements hydromécaniques, l'énoncé comprend un sous-détail par matériau du prix offert. Les quantités ont été respectées par l'entreprise et un prix sur chaque article a bien été indiqué par GOBI. Il conviendrait d'exiger du soumissionnaire qu'il transmette (s'il ne l'a pas déjà fait) les fiches techniques relatives à chaque matériau ou équipement afin de vérifier si les normes, standards et spécifications techniques sont respectés.

Concernant le laboratoire et les investigations géotechniques, il est nécessaire d'exiger des explications sur l'étendue des prestations couvertes par les prix indiqués afin de vérifier si ce qui est prévu par le soumissionnaire est bien conforme ou non à ce qui est exigé dans les spécifications techniques. Il faut garder en tête qu'une partie des coûts relatifs à ces deux postes pourrait avoir été inclus dans un autre prix lié : par exemple, une partie des coûts des investigations géotechniques pourrait avoir été chiffré sous le prix « études de conception » ou « étude topographique ». En effet, si on additionne les quatre dernières lignes de prix du poste Installation, l'offre de GOBI se monte à environ 2.7 M€, soit presque identique à l'estimation sur ces quatre lignes qui se monte à 2.8 M€. Le prix offert par l'entreprise étant un prix global et forfaitaire, les tableaux de prix sont donnés à titre indicatif et l'entreprise n'est pas engagée sur chaque prix unitaire mais sur le prix global : elle peut donc avoir choisi de décomposer ses prix comme elle l'entend.

Le prix « Mobilisation » proposé par GOBI est très inférieur à l'estimation et au prix de Eiffel. Il est incontournable d'exiger une décomposition détaillée de ce prix (pas fournie avec l'énoncé) pour déterminer d'éventuelles incohérences avec les promesses de réalisation indiquée dans la méthodologie de l'offre technique ou des manquements avec les exigences de la description des travaux et des spécifications techniques. Si on procède comme précédemment en regroupant les 6 premiers prix du poste Installation (voire du montant total de ce poste), l'écart avec l'estimation de la maîtrise d'ouvrage sera réduit mais reste considérable : 3.17 M€ pour l'estimation contre 1.81 M€ proposés par GOBI. Il faut donc effectuer des investigations plus poussées pour comprendre comment GOBI a pu proposer un prix nettement inférieur à l'estimation pour sa mobilisation de chantier. Des explications acceptables pourraient être proposées : existence d'un chantier en cours à proximité, base du partenaire local (qui apporte les engins de travaux par exemple) très proche du site des travaux. Si aucune incohérence avec l'offre technique ou non-conformité avec les spécifications techniques ne peut être mise en évidence, l'offre ne pourra pas être rejetée. Dans la situation contraire, les dispositions de la clause 36 des IS permettent un rejet automatique de l'offre : les conséquences des incohérences ou non conformités n'ont pas à être évaluées. Le principe est d'avoir une politique de tolérance zéro pour un soumissionnaire qui propose un prix d'offre très bas, ce qui représente en soi un risque élevé pour la maîtrise d'ouvrage.

En conclusion, les données de l'énoncé ne permettent pas de conclure au rejet de l'offre en application des dispositions de la clause 36 des IS. Des investigations complémentaires sont nécessaires, surtout sur la décomposition des prix relatifs à la mobilisation de l'entreprise.

4. Examen de l'éligibilité du groupement GOBI à un financement AFD

L'information selon laquelle un membre du groupement GOBI a connu une résiliation de marché nous interpelle car elle fait écho à un des cas d'exclusion à un financement de l'AFD listés dans les Directives

de passation des marchés de l'AFD. Un examen attentif de l'énoncé du cas numéro 4 de la liste des cas d'exclusion des Directives met en évidence qu'il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions pour appliquer ce critère : (1) la résiliation doit être prononcée pour défaillance aux torts exclusifs de l'entreprise, (2) la résiliation doit avoir été prononcée dans les cinq dernières années, (3) la résiliation n'a pas été contestée ou, si elle l'a été, les torts exclusifs de l'entreprise ont été confirmés.

Sur demande de clarification de la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise a reconnu l'existence de cette résiliation prononcée à ses torts exclusifs (ayant eu lieu il y a moins de cinq ans). Cependant, elle a contesté la décision de résiliation et le différend est allé en arbitrage. La décision d'arbitrage n'ayant pas été rendue, il n'est pas possible d'appliquer l'exclusion au titre de ce critère car la condition (3) ci-dessus n'est pas remplie.

Doit-on en rester là ? L'examen des critères de qualification (un extrait du rapport d'évaluation de la préqualification est fourni dans l'énoncé) fait ressortir l'existence d'un critère lié aux antécédents de non-exécution de marchés. L'entreprise n'aurait-elle pas dû faire mention de cette résiliation en remplissant le formulaire ANT-2 de déclaration des antécédents de non-exécution de marchés ? Un examen attentif de la note de bas de page n°1 montre que, en fait, la déclaration est à faire aux mêmes conditions que celles indiquées plus haut relatives au cas d'exclusion de l'AFD pour résiliation. Ainsi, l'entreprise est dans son bon droit de répondre qu'elle n'avait pas à indiquer cette résiliation dans le formulaire ANT-2 car elle l'a contestée et la décision d'arbitrage n'est toujours pas rendue. Il n'est donc toujours pas possible d'exclure le groupement GOBI sur ces bases.

Des yeux particulièrement aiguisés auront cependant noté que le formulaire ANT-2 rempli par le soumissionnaire GOBI et inclus dans l'énoncé possède non seulement un critère de marchés non exécutés mais également une rubrique « Litiges en instance » à remplir. Le membre du groupement GOBI a coché la case « pas de litige en instance ». Le critère de qualification auquel il est fait référence (section III critère 2.3) est le suivant :

2.3 Litiges en instance	L'ensemble des litiges en instance ne doit pas représenter au total plus de cent pour cent (100 %) du montant total des fonds propres du Soumissionnaire et doit être considéré comme étant tranché à l'encontre du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère.	Sans objet	Doit satisfaire au critère.	Formulaire ANT - 2
--------------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------------------------	--------------------

Même si l'ensemble des litiges en instance de l'entreprise ne représente pas 100% du montant de ses fonds propres, le critère ne précise aucune restriction quant à la nécessité de déclarer tous les litiges en cours. Ainsi, l'entreprise a fait une fausse déclaration en cochant la case correspondant à l'absence de litiges en cours.

Or, le cas n°7 de la liste d'exclusion des Directives de l'AFD est explicite sur le fait qu'une fausse déclaration constitue un motif d'inéligibilité à l'attribution d'un marché financé par l'AFD. Au titre de cette fausse déclaration, le groupement GOBI peut être exclu de l'appel d'offres en cours.

5. Recommandation générale à la maîtrise d'ouvrage

Au regard de ce qui précède, le groupement GOBI n'est pas éligible à un financement de l'AFD au titre d'une fausse déclaration sur cet appel d'offres concernant les litiges en cours. Cette exclusion est juridiquement fondée en l'état. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres motifs potentiels d'éviction qui sont soit faiblement argumentés, soit nécessitent des investigations complémentaires.

Ce cas est basé sur un cas réel. Le groupement fautif a été notifié de son exclusion du processus d'appel d'offres pour fausse déclaration et le marché a été attribué au second moins-disant.